

1500267-77.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... de São Paulo da "Rota Caipira" do tráfico, que liga a Bolívia à cidade de São Paulo, deixando partes do entorpecente pela rota. Como a cocaína não é produzida no Estado de São Paulo, evidente que está caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Os réus foram presos em flagrante, sendo concedida a liberdade provisória à ré Lency mediante imposição de medidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500267-77.2022.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-77.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE ORELLANA SOLIZ e outros

Justiça Gratuita

VISTOS

JOSUE ORELLANA SOLIZ (CPF 232.716.368-42 e RNM V466231-9), LENCY CALLAU URAPOVI (CPF 242.202.178-60), BERMAN LUIS CESPEDES LOPES (CPF 242.214.728-39), JULIA ALCIRA PEREYRA JUSTINIANO (CPF 244.690.708-31 e CI Bolivia 6281450) e MAYCOL PEREYRA (CPF 900.158.458-69), todos com dados qualificativos nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 18h30, na Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior-capital, próximo do pedágio de Itirapina, nesta cidade e comarca de São Carlos, transportavam 30 (trinta) tijolos de cocaína, com peso líquido de 30 Kg (trinta quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. narrado no boletim de ocorrência as fls. 81/85 e auto de exibição e apreensão as fls. 87/88, e consoante laudo de constatação de fls. 90/92 e laudo de exame toxicológico de fls. 196/198). Consoante apurado, na data dos fatos, a inteligência da polícia civil deflagrou ação, após receberem informações de que ocorreria um transporte de drogas na Rodovia Washington Luís, com detalhamento da marca e do modelo do veículo que

seria utilizado. Diante disso, uma viatura caracterizada ficou aguardando no pedágio enquanto outras viaturas descaracterizadas passaram a patrulhar a rodovia em busca de um veículo marca Mitsubishi, modelo Pajero. Por volta de 18h30, uma das viaturas descaracterizadas visualizou um veículo com essas características próximo ao Posto Castelo e tentou realizar a abordagem, porém ao sinalizarem como uma viatura policial, o veículo aumentou a velocidade, sendo acompanhado pela viatura até o pedágio, onde foi abordado com o auxílio da viatura caracterizada que lá se encontrava. Os denunciados eram os ocupantes do veículo abordado, sendo que o denunciado JOSUE era quem conduzia o automóvel. Em revista ao veículo, constatou-se que havia 30 tijolos de cocaína, sendo que parte deles estava em uma caixa de papelão no porta-malas e a outra parte disposta no assoalho interno do veículo. A denunciada Julia Alcira afirmou que havia sido contratada para buscar o entorpecente em São Carlos e leva-lo para a capital do Estado. Assim, está claro que os denunciados estavam transportando o entorpecente no trecho interior-capital do Estado de São Paulo da "Rota Caipira" do tráfico, que liga a Bolívia à cidade de São Paulo, deixando partes do entorpecente pela rota. Como a cocaína não é produzida no Estado de São Paulo, evidente que está caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Os réus foram presos em flagrante, sendo concedida a liberdade provisória à ré Lency mediante imposição de medidas cautelares, convertidas em prisões preventivas as dos demais (fls. 129/132 ).

Expedida as notificações, os réus, através de seus defensores, apresentaram defesa preliminar (fls. 298/302, 313/320 e 379/389). A denúncia foi recebida (fls. 395) e os réus foram citados.

Durante a instrução criminal foram inquiridas três testemunhas de acusação e os réus foram interrogados (fls. 517/518) Nos debates a Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação dos réus sem a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/06 (fls. 518). A defesa dos réus Julia Alcira Pereyra Justiniano e Maycol Pereyra pediu inicialmente a absolvição dos mesmos por insuficiência de provas porque a confissão deles não é prova absoluta e suficiente para impor condenação, acrescentando, em relação a Julia, que a mesma foi atraída pela rede do tráfico diante de sua condição de miserabilidade e atuando como "mula", promovendo função hierarquicamente baixa. Em segundo plano pediu para os réus a aplicação da pena mínima, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do redutor do § 3º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, como também a aplicação do regime mais brando (fls. 530/542). Por último, a Defesa dos réus Josue Orellana Soliz, Lency Callau Urapovi e Berman Luís Céspedes Lopes pugnou pela absolvição dos mesmos sustentando que Josue foi contratado por Júlia para fazer uma corrida como UBER, ignorando completamente que se tratava de transporte de droga, vindo com ele como acompanhantes sua mulher Lency e Bernan, tomando conhecimento da situação somente quando da abordagem policial, inexistindo provas da participação deles no delito. Subsidiariamente, em caso de condenação, que seja imposta a pena mínima com reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do redutor previsto, fixação do regime aberto e substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se a ré Lency em prisão domiciliar (fls. 543/561).

É o relatório.

D E C I D O.

Policiais da Delegacia de Entorpecentes (DISE), através do serviço de inteligência, receberam informações de transporte de droga pela Rodovia Washington Luís, com indicação inclusive do veículo que seria usado nesta atividade. Então deram início ao patrulhamento nessa via, que já vinha acontecendo fazia dois dias. Na data posta na denúncia o veículo foi visto transitando no sentido capital e foi seguido até o pedágio, onde foi possível a abordagem. No carro estavam os réus, que era conduzido pelo acusado Josue Orellana Soliz, onde foram encontrados trinta "tijolos" de cocaína, que eram transportados em duas caixas, mas alguns dos pacotes estavam espalhados na porta, assoalho e debaixo dos bancos, na tentativa frustrada de

ocultá-los no momento da abordagem (fls. 517/518).

Toda a droga, que pesou 32,54 kg, está mostrada na foto de fls. 93 e submetida ao exame de constatação (fls. 90/92) e ao toxicológico definitivo (fls. 196/198), o resultado foi positivo para cocaína, substância alucinógena e causadora de dependência física e psíquica, comprovando-se, por conseguinte, a materialidade do crime.

Sobre a autoria, convém separar o exame de cada conduta dos acusados.

Todos os acusados são oriundos da Bolívia, mas estão radicados no Brasil, no Estado de São Paulo, já faz alguns anos, exceto Maycol Pereyra, que veio em data mais recente, com objetivo de retorno ao país vizinho.

A ré Julia Alcira Pereyra Justiniano assumiu toda a responsabilidade pela atividade criminosa. Disse que foi contratada por terceira pessoa, que não soube ou não quis identificar, para vir ao interior (Campinas) buscar o entorpecente e fazer o traslado até a capital, pelo pagamento de R\$ 1.000,00, não sabendo inicialmente qual era a quantidade e depois foi falado que seria de 5 kg. Então contratou Josue, que já conhecia e costumava realizar alguns carretos, para trazê-la em troca do pagamento da gasolina, dizendo a ele que vinha buscar uma encomenda, sem informar que era droga. Na viagem Josue apareceu com a mulher, Lency, e o marido de uma sobrinha dele (Berman), que queriam fazer o passeio. Maycol, que estava de visita na casa dela, para não ficar sozinho no imóvel também veio junto. Recebeu do contratante a quantia de seis mil e novecentos dólares, dinheiro que deveria ser entregue à pessoa que entregaria a droga. Os contatos com tal pessoa eram pelo telefone. Chegando todos em Campinas, onde manteve contato com o contratante, ficou sabendo que a droga a ser apanhada estava em São Carlos. Pensou em desistir, mas acabou concordando em continuar a viagem, com a concordância de Josue. Chegando a São Carlos recebeu a indicação do local, uma casa abandonada, onde se encontrou com dois rapazes e recebeu a encomenda, verificando que era uma quantidade maior. Mesmo assustada com a situação, foi orientada a levar o produto que estava em duas caixas, que foram colocadas no carro de Josue, espalhando os pacotes debaixo dos bancos. Foi nesse momento que Josue ficou sabendo que se tratava de droga, assustando-se ao ver os pacotes. Seguiram na viagem de volta, quando foram abordados pela polícia ao atingir um pedágio (fls. 517).

Assim, diante da expressa confissão e das circunstâncias em que se deu a apreensão, a autoria e o envolvimento de Julia no crime estão demonstrados, dispensando-se outras fundamentações.

Em relação Josue Orellana Soliz, que era o dono do veículo e quem fazia o transporte da droga, também não existe dúvida da sua participação no crime, a despeito da negativa apresentada, de que apenas foi contratado por Julia para fazer uma viagem (corrida de Uber), ignorando que ela estava indo buscar droga.

Contou Josue que conhecia Julia e que recebeu um telefonema dela pedindo para fazer uma corrida até Campinas, para se encontrar com uma amiga. Aceitou porque era um domingo, estava chovendo e não ia trabalhar. Ela se encarregou de colocar gasolina no seu veículo, uma Pajero. Como estava de briga com sua mulher, Lency, a convidou para ir junto a fim de agradá-la. Foi buscar Julia na casa dela em Guarulhos, onde também estavam Maycol, sobrinho dela, e Berman. Os três entraram no veículo e seguiram para Campinas, onde Julia manteve contato com alguém e então ficou sabendo que deveria vir até São Carlos. Não soube explicar porque Maycol veio junto. Foi convencido por Julia a vir a São Carlos porque estavam no meio do caminho. Julia passou o endereço onde tinha que vir em São Carlos. Chegaram a uma casa onde desceram Julia e Maycol, enquanto ele, Lency e Berman ficaram no veículo. Viu dois rapazes que saíram da casa e colocaram duas caixas no porta-malas. Naquele momento não desconfiou de nada e não perguntou. No caminho de volta, ao atingir um pedágio,

chegou uma viatura. Até ali não percebeu que estava sendo seguido. Ao se aproximar do pedágio viu que Maycol e Julia mexeram nas caixas, fazendo movimentos. Foi depois da abordagem policial que tomou conhecimento que Julia tinha vindo buscar droga, que era o que tinha nas caixas colocadas em seu veículo.

Essa versão de Josue não se sustenta. Basta verificar o conflito entre as versões, especialmente como se deu a vinda deles a São Carlos. Enquanto Julia e Josue afirmam que vieram todos juntos, Lency, mulher de Josue, Maycol, sobrinho de Julia e Berman contam de forma diferente. Lency relata que Julia e Maycol já estavam em São Carlos e que Julia tinha pedido inicialmente a Josue para ir busca-la em Campinas e depois mudou que era em São Carlos. Vieram no veículo ela, o marido e Berman. Maycol disse que tinha vindo a São Carlos de ônibus com a tia Julia e que depois chegaram de carro Josue, Lency e Berman. Este último também relatou que veio com Josue e Lency e que Julia e Maycol já estavam em São Carlos e quando chegaram na cidade de Campinas Julia passou o endereço daqui (depoimentos gravados a fls. 517).

Também as explicações que os réus forneceram sobre o acontecido em São Carlos não são as mesmas, cada um fazendo relato diferente.

Impossível aceitar, considerando todas as circunstâncias do ocorrido, que Josue ignorasse que a realidade da viagem era para transportar droga. Não iria, cegamente, acreditar que se tratava de uma viagem normal, diante de todos os percalços que aconteceram no caminho. A ida inicialmente a Campinas, depois ligações e mudança de destino. Chegada em local suspeito aqui em São Carlos, contatos de Julia com estranhos e carregamento de caixas no veículo sem que questionasse a situação. E se ficou sabendo no momento da colocação das caixas que se tratava de droga, como disse Julia, deveria recusar o transporte. E na rodovia certamente percebeu que estava sendo seguido pela polícia e mesmo vendo Maycol e Julia tentando esconder os pacotes pelo interior do veículo, continuou a marcha até se ver sem saída ao atingir o pedágio.

Ainda oportuno mencionar o fato de que os policiais, dias antes, tinham obtido informações indicando as características do veículo que transportaria a droga, situação que derruba o álibi de Josue e revela que a empreitada criminoso já estava sendo entabulada bem antes do dia da apreensão.

Aceitar a negativa de Josué será desprezar as evidências que estão nos autos e que o incriminam sem nenhuma dúvida, impondo-se a sua condenação.

Quanto ao réu Maycol Pereyra, sobrinho de Julia, melhor sorte não tem, porque os elementos contidos nos autos o incriminam também.

Ao contrário do que disse Júlia, Maycol informou que veio até São Carlos em companhia desta para "pegar uma coisa", falando depois que era uma mercadoria que tinha que receber sem explicar o que se tratava. Vieram de ônibus saindo de Guarulhos e chegando aqui em São Carlos por volta das 17 horas. Foram até uma casa caminhando e antes de chegar ao local sua tia Julia disse que ia levar droga para São Paulo sem explicar quanto levaria. Acredita que ela trouxe dinheiro, mas não a viu entregando. Na casa tinham duas pessoas. Não ouviu o que Julia conversou com essas pessoas. Na casa tinham duas caixas e no interior delas viu os pacotes. Julia ligou para Josue vir busca-la, mas não sabe quando ela ligou. Josue veio com a mulher Lency e Berman. Sua tia tinha lhe dado um celular e depois deu outro. Confirma ser a pessoa da foto de fls. 512 e que as caixas com os pacotes que aparecem na foto foram tiradas por Julia no local onde estavam e que as pernas que aparecem em uma das fotos são suas. Sobre a foto onde aparece manuseando dinheiro disse que foi tirada na casa de Julia em outra ocasião. Confirmou que no caminho de volta, ao perceber que estavam sendo seguido, retirou de uma das caixas os pacotes

com a droga e tentou escondê-los na porta, debaixo do banco e do tapete do veículo.

Assim, ao acompanhar Julia até São Carlos e mesmo ciente aqui de que ela veio buscar droga, manteve-se em companhia da mesma, sendo visto manuseando dinheiro, certamente os dólares do pagamento, como também fotografado junto às drogas que foram transportadas, além da tentativa de ocultá-la no momento que antecedeu a abordagem, coloca Maycol como coadjuvante do crime.

Com toda certeza Maycol aceitou acompanhar Julia, emprestando a esta não apenas companhia, mas aderindo à ação criminosa da mesma e assumindo relevante papel na execução do crime. Tudo indica que ambos vieram antes para as tratativas e providências, quando Julia, diante da quantidade de droga que teria que ser transportada, acertou com Josue a vinda deste para completar o serviço para o qual Julia fora contratada.

Portanto, a condenação de Julia Alcira Pereyra Justiniano, Maycol Pereyra e Josue Orellana Soliz é medida que se impõe, não podendo ser outro o resultado.

Mas não tem aplicação a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porque não ficou demonstrado que se tratou de transporte de droga interestadual. Para o reconhecimento desta majorante haveria necessidade de comprovar que o tráfico em julgamento envolveu mais de um Estado da Federação.

No que respeita à aplicação para esses réus do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, entendo não ser possível o reconhecimento deste abrandamento que exige, além da primariedade e de bons antecedentes dos réus, que os mesmos não se dediquem a esse tipo de atividade e nem sejam integrantes de organização criminosa.

Nesse sentido a doutrina Luiz Flávio Gomes e outros: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal” (LEI DE DROGAS COMENTADA, Revista dos Tribunais, 2ª Ed., 2007, p. 197).

Os réus, embora sejam primários, aceitaram transportar quantidade considerável de droga e de natureza mais nociva (cocaína), colaborando com organização criminosa que promove o tráfico. Estavam, pois, vinculados indiretamente a uma atividade criminosa antecedente ao crime que cometeram, o que lhes retira o direito da redução de pena.

A concessão indiscriminada dessa benesse contraria o espírito da repressão penal mais severa que foi introduzida com a Lei nº 11.343/06. E a intenção do legislador ao criar esse redutor, foi dispensar tratamento diferenciado ao “traficante menor” em detrimento do “traficante organizado”. E aqui, como já afirmado, os réus estavam colaborando com este segundo grupo.

O reconhecimento do crime privilegiado não se trata de regra obrigatória baseada apenas na primariedade, facultando ao magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso examinado. Por conseguinte, para casos como este, em que a quantidade de droga é elevada e pertencente a organização criminosa que se dedica à prática dessa espécie de crime, não vejo a possibilidade de concessão aos réus de pena reduzida, reservada para casos de contornos menos gravosos, que não é a hipótese aqui examinada.

Em relação ao réu Berman Luis Cespedes Lopes, a prova não favorece a pretensão acusatória. O que tem contra este réu é o fato de ele se encontrar no veículo com os outros acusados. Alegou que veio no veículo para passear, ignorando que a viagem

era para transporte de droga, tomando conhecimento desta situação quando já estavam voltando e na proximidade do pedágio, no momento em que Maycol começou a retirar os pacotes da caixa.

Nenhuma prova foi produzida de ligação dele com o transporte da droga, especialmente qual seria o seu envolvimento com a operação acontecida. O que se tem a respeito, como já afirmado, é apenas a presença dele no veículo, situação que não o coloca como coautor ou participe do crime que lhe foi imputado.

Como já ficou decidido, em lição antiga, mas sempre presente: "Co-autoria não se presume. Deve ser traduzida em atos sensíveis e inspirados por vínculos subjetivos e aferíveis entre os delinquentes, que por tal circunstância, passam a ser co-delinquentes" (TJSP - HC - Rel. Humberto da Nova - RT 461/317).

Como já visto, a acusação está baseada única e exclusivamente na presença de Berman no veículo com os demais acusados e que estão sendo responsabilizados. Nenhuma outra prova foi produzida para vincular este réu com a atividade criminosa dos demais acusados. E não é possível, pelo simples acompanhamento reconhecer sua responsabilidade pelo crime. Impossível extrair desse fato o convencimento que se exige do julgador no momento de proferir uma decisão condenatória. Não, não se forma a certeza suficiente e indispensável sobre a realidade dos fatos e da participação de Berman no crime.

Oferecida a denúncia, o "onus probandi" pertence ao Ministério Público. Cabe-lhe demonstrar de forma cabal a autoria atribuída na peça inaugural do processo. Se não o fizer, absolve-se o denunciado, porque a presunção de inocência milita em seu favor. O princípio "actore non probante absolviatur reos" vem consagrado no Código de Processo Penal, no seu artigo 386, item VII.

Nesse sentido a jurisprudência:

"Tráfico ilícito de entorpecentes. Insuficiência de provas. Absolvição mantida, inexistente nos autos prova segura de que o réu praticou o crime, a improcedência do pedido de condenação é medida que se impõe" (TJDF. 20040111057455, Rel. Getúlio Pinheiro, 2ª Turma Criminal, julgado em 30/04/2009, DJ 19/08/2009, p. 138).

"Se a prova não permite aferir indene de dúvida a participação do acusado na prática delitativa, a manutenção da absolvição é medida de rigor. Apelação do Parquet a que se nega provimento em observância ao princípio do in dubio pro reo" (Apelação Criminal n. 2010.008958-8 - Bandeirantes - Relator Des. Carlos Eduardo Contar - julgamento 02/08/2010 - 2ª Turma Criminal).

"É de se invocar a prevalência de dúvida se a prova é frágil a embasar um Decreto condenatório, prevalecendo o brocardo in dubio pro reo" (TJMG, ap. 0784632-42.2009.8.13.0687, 4ª Câmara Criminal, rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, julg. 27/4/2011, DJEMG 11/05/2011).

Assim, o quadro probatório apresentado inspira dúvida sobre a autoria e participação de Berman e não resolve, com a indispensável certeza que se exige para uma condenação, que este acusado estava deliberadamente contribuindo e coadjuvando a ação que se desenvolvia de transporte da droga, motivo pelo qual a sua absolvição deve ser decretada.

Por último, no que respeita à ré Lency Callau Urapovi, igualmente não encontro prova suficiente para condená-la.

Lency é mulher de Josue e o acompanhou na viagem. Contou em seu interrogatório: "é mulher de Josue; ele disse que ia fazer UBER, levar Julia, que já conhecia, até Campinas, para buscar um produto ou encomenda; quis ir junto e largou a filha com sua mãe; Berman, que é marido da sobrinha de Josue, que sempre saía com eles, quis

acompanha-los; em Campinas receberam outra chamada de Julia e vieram para São Carlos; ela Josue e Berman; Julia estava em São Carlos, esperando em um estacionamento; ela não foi junto com eles até Campinas; ela estava com o sobrinho Maycol em São Carlos; em Campinas ela ligou e pediu para pegar ela em São Carlos, onde já estava com o Maycol; aqui chegaram os três num posto; ela chamou para Josué pegar eles numa casa; ali estavam dois rapazes, Julia e Maycol; colocaram umas caixas no carro; as caixas foram colocadas atrás no carro, no porta-malas e não estavam rasgadas; as caixas foram rasgadas quando estavam chegando no pedágio; Maycon queria esconder; chegando no pedágio Maycon rasgou as caixas e começou a esconder os pacotes nas portas e sob os bancos; fiquei assustada porque a polícia estava perto; só uma caixa foi aberta; Josue quis esconder nas portas, debaixo do banco, do tapete; somente ficou sabendo que era droga quando a caixa foi aberta perto do pedágio; Josue ficou nervoso e disse a Julia o que você estava fazendo; Josue não desceu do carro na casa; Julia falou que era uma encomenda; eram caixas de cor café; confirmou que eram as caixas vistas na foto de fls. 512; não sabia que nas caixas tinha droga; Josue também não sabia; só queria sair com ele para passear; pensava em voltar logo; deixou as crianças com sua mãe; foi o Maycon quem abriu e jogou as drogas; os policiais já estava encostando no carro; ninguém falou nada; não foram na casa da Julia para busca-la; da sua casa foram para Campinas; ficaram meia hora em Campinas; Julia chamou para pegar ela em São Carlos; de dentro do carro tinha acesso do banco traseiro para o porta-malas; não sabe porque ele fez isso" (fls.. 517).

Reproduzi praticamente na íntegra o depoimento desta acusada por revelar fidelidade ao descrever os fatos acontecidos dos quais presenciou.

Do que foi apurado, não transparece que Lency tinha realmente conhecimento dos motivos da viagem do marido e foi surpreendida com o acontecido.

Mas, ainda que Lency tivesse ciência ou mesmo conhecimento da atividade ilícita realizada pelo seu marido Josue, não é possível responsabilizá-la pelo crime deste. Entre ter conhecimento de um fato delituoso de outrem e dele participar, emprestando contribuição decisiva para a sua ocorrência, tem enorme diferença.

O simples conhecimento não basta para que Lency seja responsabilizada e incluída pela norma de extensão do artigo 29 do Código Penal à conduta criminosa de Josue, Julia e Maycol.

Na situação revelada nos autos, a não ser o fato de Lency ser mulher de Josue e estar viajando com ele e os demais no carro onde a droga era transportada, não há prova de que ela estava efetivamente ajustada e cooperando, de forma concreta e indubitosa, com o marido e os demais na prática do tráfico que foi constatado, consistente no transporte dos pacotes de cocaína, revelando-se temerária a acusação de coautoria ou participação delitiva fundada em suspeita e meros indícios.

Como ensina DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, nem todo comportamento constitui participação, pois "é preciso ser eficaz no sentido de haver provocado ou facilitado a conduta principal ou a eclosão do resultado. A simples adesão a uma prática delituosa não é participação" (Direito Penal, ed. De 1985, 1º vol., pág. 363).

Conhecimento e ciência da atividade criminosa de outrem e mesmo conivência com a situação, quando não se tem o dever jurídico de impedir o acontecimento, não enseja concurso.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "A simples conivência, a co-participação (*crimen silenti*) não enseja o concurso mercê da sua inoperância em face da lei. À *imputatio juris* deve jungir-se à *imputatio facti*, não podendo ser considerado autor de crime quem não contribui para produzi-lo" (RJTSP

146/295).

Assim, do contexto probatório surge a impossibilidade de responsabilizar a denunciada Lency pelo crime cometido pelos demais acusados que estão sendo responsabilizados. A prova contra ela, como aconteceu com Maycol, é precária, não havendo elementos suficientes e convincentes para alicerçar o decreto condenatório. Baseá-lo unicamente na união de cônjuge e da presença dela no veículo, constitui julgamento temerário.

E tais fundamentos também servem e reforçam a absolvição já reconhecida de Berman Luis Cespedes Lopes.

Assim, pela insuficiência de provas, a pretensão punitiva em relação aos réus Berman Luis Cespedes Lopes e Lency Callau Urapovi deve ser rejeitada, porquanto um decreto condenatório precisa estar sempre amparado em elementos de plena certeza sobre a ocorrência do crime e de sua autoria. E assim não acontecendo, impõe-se a absolvição, porque a dúvida deve ser resolvida em favor dos acusados.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA para, de início, absolver os réus Berman Luis Cespedes Lopes e Lency Callau Urapovi, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, passo a fixar a pena aos réus condenados. Observando todos os elementos que formam os artigos 59 e 60 do Código Penal, que devem ser examinados em sintonia com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tendo como fator preponderante a quantidade da droga apreendida, de forma que quanto maior a quantidade, maior é a gravidade e as consequências, pois o bem tutelado é a saúde pública e, neste caso, ela seria atingida de forma acentuada pelo número considerável de pessoas que poderiam ser prejudicadas com a quantidade expressiva de droga apreendida e que seria colocada no mercado à disposição de viciados, sendo a posse de grande quantidade de droga uma circunstância decisiva para a fixação da pena acima do mínimo legal (STF, 1ª Turma, RHC 82.369/RJ, j. 24.09.02, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 08-11-02, p. 0044). Por conseguinte, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo previsto, ou seja, a restritiva de liberdade em seis anos de reclusão e a pecuniária de 600 dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo vigente na data do crime. Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes e tendo havido confissão espontânea de Julia e Maycol. Este, mesmo não tendo confessado explicitamente, admitiu o seu envolvimento no crime e suas declarações serviram para reconhecer a sua responsabilidade e amparar o decreto condenatório, devendo a mesma atenuante ser reconhecida em seu favor. Então, para ambos, reduzo a pena restritiva de liberdade em seis meses e a pecuniária em 50 dias-multa, tornando definitivo o resultado. Para Josue, não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes, fica mantida a pena inicialmente estabelecida.

Quanto ao regime de pena, considerando decisões das Cortes Superiores e resumidas nas Súmulas nºs. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e nº 440 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a imposição do regime mais severo com base na hediondez e na gravidade abstrata do delito, bem como verificando que os réus são primários e sem informações de envolvimento reiterado com o tráfico, delibero estabelecer como regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, que reputo adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido por eles, como também para norteá-los a uma mudança de comportamento, sem transmitir impunidade.

Observo ainda que o acréscimo da pena-base, estabelecido na primeira fase, foi baseado na quantidade de droga, não podendo ser usado o mesmo fundamento para enrijecer o regime de pena para não incorrer em indevido "bis in idem". E como os réus ostentam circunstâncias subjetivas favoráveis, não existem outros motivos para impor regime prisional mais severo à luz do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que é o semiaberto.

Condeno, pois, JOSUE ORELLANA SOLIZ, às penas de seis (6) anos de reclusão e de 600



dias-multa, no valor mínimo, e JULIA ALCIRA PEREYRA JUSTINIANO e MAYCOL PEREYRA, às pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e de 550 dias-multa, no valor mínimo, todos por terem transgredido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Iniciarão o cumprimento da pena no regime semiaberto, como já exposto.

Recomendem-se os réus condenados na prisão em que se encontram, não podendo recorrer em liberdade, pois se aguardaram presos o julgamento, com maior razão assim devem continuar agora que estão condenados, permanecendo ainda os fundamentos da prisão cautelar, acrescido no momento com a possibilidade de fuga para frustrar o cumprimento da pena imposta, especialmente porque são de origem estrangeira e poderão deixar o país.

Nesse sentido a jurisprudência: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC nº 89.824/MS - Rel. Min. Ayres Brito - DJe. 28-08-2008). Também: STJ-RHC nº 111.421/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10=10-2019; RHC nº 119.468/MG, Relator Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 17-10-2019, DJe 25-10-2019; RHC nº 34.998/RJ, Relator Min. Jorge Mussi -Dje 20-03-2013).

Deixo de impor a obrigação do pagamento da taxa judiciária em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (fls. 447), benefício que estendo ao réu Josue.

A droga já foi destruída (fls. 220). Autorizo a devolução dos aparelhos celulares apreendidos.

Deixo de decretar a perda do veículo apreendido porque não se demonstrou que havia uso contínuo dele na atividade criminosa desenvolvida, evidenciando na espécie o uso ocasional. E uso esporádico de carro, sem constituir-se em elemento disseminador da traficância, impossibilita a perda desse bem em favor da União. Caberá à Defesa indicar o responsável pela retirada do veículo.

Em razão da decisão absolutória de BERMAN LUIS CESPEDES LOPES, expeça-se alvará de soltura em favor do mesmo, que será cumprido com as devidas cautelas.

P. I. C.

São Carlos, 04 de julho de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA